

1500114-82.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Tribunal de Justiça é prescindível a comprovação de que o tráfico visava aos estudantes ou frequentadores dos locais postos na lei, bastando que o tráfico se dê nas proximidades, sem outras exigências.

Nesse cenário, passo a adotar esse entendimento, traduzido no v. acórdão que se segue:

"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500114-82.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500114-82.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Campos Larcher Sales

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Gabriel de Campos Larcher Sales foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 23 de Janeiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Paulo Sampaio Santos, nº85, Bairro Estiva, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo para fins de venda a terceiros consumidores, próximo a escola municipal Miguel Ribas Branco, cerca de 100 metros de distância, 60 pinos de cocaína, com massa líquida de 13,5 gramas, 13 pedras de crack, subproduto da cocaína, com massa líquida de 3,72 gramas, conforme se verifica no laudo de constatação provisória de fls. 20/25, substâncias causadoras de dependência química e psíquica.

Segundo apurado, o réu é egresso do sistema prisional e cometeu o crime em questão durante cumprimento de pena provisória decorrente de condenação anterior imposta nos autos nº1501163-28.2020.8.26.0587, pela condenação de crime da mesma espécie (certidão de fls. 30/31), na qual lhe foi concedido o direito de recorrer em

liberdade, denotando ostentar culpabilidade e reprovável comportamento social.

Assim, na manhã dos fatos, o réu levou consigo certa quantidade de drogas escondidas dentro de uma sacola e se deslocou até o endereço mencionado, local conhecido como ponto de venda de drogas, localizado a cerca de 100 metros de distância da escola municipal Miguel Ribas Branco, onde ficou efetuando os atos de mercancia dos entorpecentes.

Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina e se depararam com o réu sentado e em atitude suspeita, resolvendo abordá-lo, encontrando no bolso de sua bermuda 3 pinos de cocaína e a quantia de R\$46,00, auferido com a traficância.

No momento em que o réu se levantou, os milicianos perceberam que sobre as nádegas do réu estava uma sacola plástica, sendo encontrado em seu interior mais 57 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e uma porção de maconha, prontas para a venda.

Questionado a respeito, o réu confessou informalmente que estava vendendo as drogas e que começou a vendê-las de madrugada.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida as fls. 59/61.

Citado (fls. 67), o réu apresentou resposta escrita a acusação as fls. 74.

Designou-se audiência, ocasião em que foi ouvida a testemunha Rogério Dinis Dias. Outra foi designada, ouvindo-se a testemunha Danilo Teles Martins, e procedendo-se ao interrogatório do réu Gabriel de Campos Larcher Sales, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência parcial do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Pediu o afastamento da qualificadora prevista na Lei de Drogas, pois, apesar de ocorrência ter se dado próximo de uma escola, era época de férias escolares, não prejudicando os estudantes. Entende que não há motivo para duvidar da palavra do policial, sendo que ele sabe as consequências que haveria acaso estivesse faltando com a verdade. Destarte, pelos dados expostos e reunidos entende que é caso de condenação. Na primeira fase da dosimetria afirmou que a pena deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase pediu o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, com afastamento da causa de aumento.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, diante da ausência de provas a corroborar os fatos afirmados. Comentou que o réu estava no local para consumo dos entorpecentes e que as condições expostas pelo o réu são compatíveis com um usuário de droga. Salientou que o detentor da droga foi escolhido por ter antecedentes criminais. Aduziu que a região monitorada estava em pleno poder dos policiais havendo a falha da acusação ao acreditarem que somente as palavras das testemunhas apresentadas bastam. Não negou a idoneidade da palavra dos policiais militares, contudo devido às teses conflitantes, pediu a absolvição pelo in dubio pro reo. Aduziu que concorda com o Ministério Público pela fixação da pena-base no mínimo legal e afiançou o pedido do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termos de depoimento (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de apreensão (fls. 18), laudo pericial (fls. 20/25), relatório final (fls. 28/29) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Rogério Diniz Dias, ouvida em juízo, informou que estavam em patrulhamento pelo bairro Parque São Cristóvão quando visualizaram o indivíduo que demonstrou nervosismo ao ver a viatura e decidiram abordá-lo. Declarou que foram localizados 3 pinos de cocaína e R\$46,00 e ao revistarem o local em que ele estava sentado encontraram uma sacola com mais 57 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e uma porção de maconha, e que o réu confirmou a prática da mercancia dos entorpecentes. Informou que não conhecia o réu, mas narrou que ele informou a equipe que já havia sido preso. Declarou que o réu estava acompanhado de mais uma pessoa, mas em revista não foi encontrado nada com ela e que a abordagem era apenas de rotina. Confirmou que não se dirigiram até a casa do réu e que próximo a ele havia uma pessoa, mas existiam outras no local que é uma praça.

A testemunha Danilo Teles Martins, ouvida em juízo, informou que no dia da ocorrência, realizando um patrulhamento próximo à praça, iniciaram a abordagem e localizaram Gabriel sentado. Pediram que se levantasse e observaram que ele estava sentado sob uma sacola, com dinheiro e entorpecentes. Complementou que não chegou a verificar a residência do réu e que não possuía nenhuma informação prévia de Gabriel Sales, somente do local. Relatou que o réu informou que estava realizando a mercancia de entorpecentes e precisava de dinheiro. Aduziu que não viu ninguém entrando em contato ou próximo do réu. Salientou que abordaram outras pessoas na praça, contudo não encontraram nada. Informou que para manter a integridade e a segurança das pessoas do local não as chamaram para depor ou para testemunhar na delegacia.

O réu Gabriel de Campos Larcher Sales, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Salientou que estava no local para buscar droga para consumo. Comentou que havia sete a dez pessoas na praça, consumindo maconha. Relatou que comprou três pinos de cocaína com um rapaz que lá se encontrava e que antes já havia comprado mais drogas. Aduziu que é usuário e não trafica por medo de se endividar com os traficantes. Complementou que possuía R\$ 76,00, sendo que R\$ 30,00 pagou nos 3 pinos e ficou com o restante para consumo de alimentos, cigarros e bebidas. Comentou que não estava trabalhando. Salientou que possui passagem por tráfico de drogas e que é usuário de drogas desde os treze anos. Informou que já utilizou maconha, crack e hoje consome cocaína. Afirmou que o traficante foi juntamente abordado, contudo ao informarem seus antecedentes criminais obtiveram tratamentos diferenciados.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo trazer consigo do núcleo do tipo, resultando, assim, configurada a traficância.

A própria prisão em flagrante do réu deu conta de que trazia consigo drogas, ao ter em seus bolsos e próximo ao seu corpo em uma sacola, quantidade de entorpecente que demonstra não outra coisa que não a destinação para o comércio ilícito.

Registre-se que os depoimentos prestados pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos descenderam a minúcias, retratando o fato como realmente passado.

Disseram que passavam em patrulha por local conhecido pelo tráfico intenso e, ao se depararem com o réu resolveram abordá-lo encontrando no bolso da bermuda 3 pinos com cocaína e dinheiro e, embaixo dele, em uma sacola plástica, mais cocaína, crack e maconha.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Dessa forma não há qualquer dúvida acerca do fato e da responsabilidade do réu pelo evento criminoso.

Quanto às teses defensivas, nenhuma delas é capaz de infirmar os fatos efetivamente provados.

A negativa do crime trazida tanto em autodefesa como em defesa técnica não se mostra crível e não encontra qualquer respaldo nas provas, que só fazem incriminá-lo.

Com efeito, não havia motivo algum para que os policiais o incriminassem com mais drogas além daquelas que portava em seu bolso, mesmo porque sequer o conheciam. Essa tese levantada pressuporia que os policiais seriam corruptos e que incriminariam qualquer pessoa escolhida ao acaso, o que se mostra irrazoável.

Não se vê, nesse ponto, qualquer motivo para que os policiais agissem dessa forma. A polícia está a serviço da justiça e, com exceção de alguns poucos casos – que sempre são reprimidos de forma severa – a quase que totalidade dos policiais é

honesto e não se presta a perpetrar delitos. A alegação busca somente livrar o réu de sua certa responsabilidade.

O que se verifica, mais uma vez, é uma tentativa desesperada de atribuir aos policiais, que atuam ao lado da lei, a responsabilidade que é do réu, desviado em sua conduta, valendo-se de meios ilícitos e ilegais para obter dinheiro fácil.

Ademais, o réu não realizou qualquer prova dos fatos que alega e sua versão resulta escoteira nos autos, sem qualquer respaldo.

A propósito da questão, registro que alegação dos policiais - tomadas por verdadeira porque, como afirmado, não tem interesse nenhum na condenação de inocentes - vem corroborada pela droga e pelo dinheiro sem procedência lícita encontrado com o réu - que declarou não ter atividade lícita.

A alegação de que não há provas suficientes à condenação contrasta com as provas efetivamente produzidas, que consistem na oitiva dos policiais e na droga apreendida em poder do acusado.

O fato de haver outras pessoas no local não demandaria dos policiais que fossem elas levadas para a delegacia como testemunhas, mesmo porque já havia a versão dos dois policiais que realizaram a abordagem.

Ademais, poderia o réu trazer eventuais testemunhas que ali se encontravam, porém, quedou-se inerte, não se desincumbindo desse ônus.

Quanto à imputação de que o tráfico se dava nas imediações de escola municipal, o Ministério Público entendeu não aplicável por se tratar de período de férias.

Este Juízo outrora já adotou esse entendimento, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se em sentido contrário, no que tange à aplicação do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é prescindível a comprovação de que o tráfico visava aos estudantes ou frequentadores dos locais postos na lei, bastando que o tráfico se dê nas proximidades, sem outras exigências.

Nesse cenário, passo a adotar esse entendimento, traduzido no v. acórdão que se segue:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24.5.2021).

A prova é certa, segura e dá conta do cometimento do crime pelo réu, que deve responder pelo ilícito praticado.

Estabelecida a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A despeito da quantidade de eppendorfs encontrados com o réu, a quantidade líquida da droga é considerada natural ao delito, não se mostrando hábil à elevação da pena.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. De forma censurável e injustificável, acusou falsamente os policiais que apenas cumprem com seu dever institucional, atribuindo-lhes a prática de crime. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do

Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis,

publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Cabe anotar, em remate, que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decísmo que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.ª Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

No que respeita à culpabilidade o que se vê é natural à espécie.

Acerca da conduta social do réu não se tem elementos para sua valoração.

O réu não possui antecedentes criminais, salvo uma condenação anterior que será objeto de consideração na segunda fase da aplicação da pena por ter se configurado

a reincidência.

Os motivos do crime e as circunstâncias são naturais ao tráfico de drogas, bem como as consequências dele decorrentes, nada havendo a valorar.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, então, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na fixação da pena-base, considerando-se a personalidade negativa do réu, elevo a pena em 1/6, alçando-a para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não se vislumbram circunstâncias atenuantes. Observo, contudo, a agravante da reincidência pelo processo 1501163-28.2020, da Comarca de São Sebastião, que demanda agravar a pena em 1/6, alçando-a a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, fixando-se definitivamente a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

O regime inicial para o crime apenado com reclusão será o fechado.

Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado – o réu perpetrou o crime enquanto cumpria pena pela condenação anterior pelo mesmo crime, tratando-se, pois, de reincidente específico.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, e por se tratar de réu reincidente específico, a substituição é vedada pela lei.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anote-se, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente'" (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF – HC n. 89824/MS – 1ª T. – unânime – Min. Carlos Ayres Britto – DJe 28/8/2008; STF – HC n. 114536/MG – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 4/12/2012; STJ – HC n. 222002/RJ – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/10/2013).

No caso o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno, mormente considerando que cometeu o delito quando ainda cumpria pena por condenação anterior pelo mesmo crime, cuidando-se, pois, de reincidente específico. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

O tráfico é crime de enorme gravidade, nefasto, que dissemina as drogas e deturpa a sociedade, destruindo seres humanos e lares e que ampara todo o mundo da criminalidade.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão do réu (artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permanece preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União Federal.

Anoto que com relação ao dinheiro, não foi comprovado que tenha origem em trabalho lícito labor, impondo-se, pois, o seu perdimento.

Registro que seriam fatos de prova relativamente facilitada por meio de documentos, que, no caso concreto, seria o único meio hábil à comprovação das alegações, mas que não vieram para os autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu

Gabriel de Campos Larcher Sales à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa como incurso no artigo 33, caput e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03, observada a gratuidade da justiça. Condeno, ainda, ao perdimento do valor apreendido.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 5 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA